

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

O Poder constituinte é a prerrogativa de **elaborar ou atualizar uma Constituição**. Sua teoria foi inicialmente desenvolvida pelo abade francês **Emanuel Sieyès** - camarada que costuma comparecer na sua prova -, em sua obra "O que é o Terceiro Estado", de 1789, na qual apontava como titular do Poder Constituinte **a nação**. Segundo ele, a nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Antes dela e acima dela só existe o direito natural.

A nação foi considerada por Sieyès herdeira do direito natural, única legítima para se opor ao governo absoluto do rei, constituído pelo **direito positivo**. Seu axioma é: *A nação se forma unicamente pelo direito natural. O governo, ao contrário, não pode pertencer senão ao direito positivo*. Desse princípio, ele deduz que a nação não está e nem pode ser submetida a uma Constituição, pois esta subjugava o governo, a estrutura de poder temporariamente reinante. A nação não é constituída pelo estado senão **constituente** deste. Daí o termo poder constituinte em Sieyès. O 1º Estado era a nobreza, o 2º Estado, o Clero, ambos abrangendo mais ou menos 200 mil indivíduos e o 3º Estado, os comuns, 25 ou 26 milhões de pessoas.

O poder constituinte estrutura o exercício do poder político, determinado os termos em que as autoridades públicas, inclusive os legisladores, poderiam licitamente atuar. Tal poder, que pertencia à Nação, além de criar os "poderes constituídos", fixava-lhes limites: "nenhuma espécie de poder delegado pode mudar nada nas condições de sua delegação".

Para Sieyès, a **nação** era a fonte única da qual emanavam todos os poderes.

Até essa época, o exercício do poder estatal era justificado pelo **direito divino** e pela **hereditariedade**. Os monarcas eram coroados pelo Chefe da Igreja Católica. Nessa vertente, Deus era o titular do poder e o exercia por intermédio de seu representante na Terra, o rei. Por sua vez, o monarca transmitia esse poder aos seus descendentes. Um dos que primeiramente se insurgiu contra essa prática foi Napoleão Bonaparte, que em 1804, quando o papa ia coroá-lo imperador, tomou-lhe das mãos a coroa e corou a si mesmo e a Josefina, instituindo o estado **secular** francês (separação entre Estado e igreja).

A partir das revoluções liberais, notadamente a de 1789 na França, as nações absolutistas foram sendo substituídas por democracias representativas, não obstante a França retorne à monarquia com Napoleão, em 1804. Foi sendo universalizado o sufrágio, o direito de voto, de escolha dos representantes, colocando-se como **titular do poder constituinte o povo**, principalmente sob a égide das ideias de "**O Federalista**", redigido pouco antes do livro de Sieyès. A soberania popular foi assentada como conceito voltado para o regime político interno do Estado, diferente da soberania internacional, voltada para a política externa:

"Em todas as grandes mudanças nos governos estabelecidos, as formas cederam lugar à substância; uma rígida aderência nesses casos às primeiras tornaria apenas nominal o direito transcendente e precioso do povo de abolir ou alterar o seu governo" (**HAMILTON, Alexander, MADISON e JAY, O Federalista 40, Filadélfia, 1787**)

A ideologia nacionalista defende a nação como titular do poder constituinte. Na democracia, a titularidade é do povo. Na teocracia, a Deus, que delega a seus representantes (o rei) o exercício do poder. Nos Estados socialistas, a classe operária.

Portanto, guarde que, modernamente o poder constituinte tem como titular **o povo**, o que é cobrado de forma recorrente pelas bancas. Veremos, no entanto, que nem sempre será por meio do povo, diretamente, que o poder constituinte se manifestará. Muitas vezes, por intermédio de representantes eleitos, um Conselho ou mesmo por um grupo revolucionário que toma para si a iniciativa de implantar uma nova ordem constitucional.

Como veremos mais adiante, o Poder Constituinte Originário não é um poder jurídico, mas sim um poder político, sendo inicial e com seu fundamento de validade anterior à ordem jurídica. Por isso, ele é o poder que organiza o Estado. Quando o poder constituinte originário se manifesta, o Estado está se reorganizando criando uma nova ordem jurídica.

Tradicionalmente, o poder constituinte segmenta-se em **originário** e **derivado**.

Poder Constituinte Originário (PCO):

É o poder de **elaborar uma nova constituição**. Pode se manifestar de duas formas distintas: na formação de um novo Estado, quando se elabora a primeira constituição (também chamado poder constituinte originário **histórico**) e na ruptura da ordem jurídica de um Estado preexistente, em que uma constituição é substituída por outra (poder constituinte originário **revolucionário**).

Essa ruptura pode ocorrer de forma democrática ou de forma autoritária, sendo que nesta última pode-se dizer que o poder constituinte originário é usurpado, temporariamente, pelos detentores *ad hoc* do poder estatal.

O poder constituinte originário possui as seguintes **características**:

i) é um poder **político**, e **não jurídico**, porque antecede a formação do ordenamento jurídico, que tem nele (PCO) seu fundamento de validade; dentro desta nova ordem jurídica estarão também sendo instituídos os demais poderes constituintes (**revisor, reformador e decorrente**). Estes poderes, então, serão chamados de **poderes constituintes jurídicos**, já que foram instituídos pelo Poder Constituinte Originário e retiram o seu fundamento de validade diretamente da ordem constitucional inovada.

ii) é um poder **ilimitado**, por não estar restringido pelo direito preexistente, não devendo obediência ao direito positivo antecessor, e podendo mesmo ultrapassar cláusulas pétreas e direitos adquiridos sob o regime constitucional prévio;

iii) é um poder **autônomo**, isto é, compete somente ao seu titular, **o povo**, representado ou não, deliberar sobre o conteúdo a ser inserido na nova ordem constitucional. Não se subordina a nenhum outro poder para exercer sua autonomia.

iv) é um poder **incondicionado**, porque não sujeito a nenhuma forma pré-definida de manifestação de sua vontade, nem para elaboração de sua obra, a Constituição;

v) é também um poder **permanente**, o que significa dizer que é **preexistente** e que não se exaure com a promulgação da Constituição, permanecendo em estado latente e podendo se manifestar a qualquer momento, seja por meio de uma assembleia constituinte, seja por ato revolucionário;

vi) Por ser ilimitado, **não poderá sofrer controle de constitucionalidade**; isto é, as normas constitucionais originárias não se sujeitam a controle de constitucionalidade, apenas aquelas alteradas/incluídas por emenda constitucional.

vii) **Fonte de validade da ordem jurídica**: constitui-se em fonte de validade da ordem jurídica, cujo parâmetro de aferição é a Constituição; uma vez identificada alguma discordância entre o parâmetro e a norma questionada, esta é expurgada do sistema jurídico, pelo controle de constitucionalidade.

viii) **Inicial**: pois instaura uma nova ordem jurídica, a partir de uma nova ordem constitucional.



Importante!

Apesar de teoricamente **ilimitado**, há doutrinadores que defendem a existência de **limites supranacionais** à atuação do **Poder Constituinte Originário**.

Desse modo, no âmbito do direito internacional, não seria admissível uma Constituição que desrespeitasse **os direitos da pessoa humana, o respeito à soberania e a independência nacional** e ainda propugnam a existência de outros limites de ordem natural (valores éticos superiores) ou de ordem lógica (não seria admitida a extinção do Estado, por exemplo). O maior expoente dessa vertente é o alemão **Otto Bachoff**, que procurou formular uma concepção de Constituição em sua conexão com a realidade social, que lhe dá o conteúdo fático e o sentido axiológico (valorativo). Para esse jurista, só há Constituição verdadeira nos Estados que consagram determinados valores políticos, ideológicos ou institucionais, fundamentados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 ou normas universais, de direito natural. Eventuais normas contidas no texto constitucional que violem esses princípios e valores supranacionais devem ser consideradas inconstitucionais, segundo Bachoff.

Contudo, para o nosso ordenamento pátrio, a posição do STF é a **positivista**, ou seja, de que não há limitações ao poder constituinte originário, não podendo as normas constitucionais originárias serem declaradas inconstitucionais:

"Ora, se uma norma constitucional infringir uma outra norma da Constituição, positivadora de direito supralegal, tal norma será, em qualquer caso, contrária ao direito natural', o que, em última análise, implica dizer que ela é inválida, não por violar a 'norma da Constituição positivadora de direito supralegal', mas, sim, por não ter o constituinte originário se submetido a esse direito suprapositivo que lhe impõe limites. Essa violação não importa questão de inconstitucionalidade, mas questão de ilegitimidade da Constituição no tocante a esse dispositivo, e para resolve-la não tem o Supremo Tribunal Federal – ainda quando se admita a existência desse direito suprapositivo – competência. A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é impossível com o sistema de Constituição rígida. (...) essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar se este teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia incluído no texto da mesma Constituição" (**ADI 815, Relator Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/1996**).

Entretanto, as bancas cada vez mais vêm assinalando que **essa limitação é de cunho jurídico-positivo e não político**. Ou seja, o poder constituinte originário não está adstrito a normas jurídicas anteriores ou mesmo normas internacionais. Entretanto, isso não significa que estamos sujeitos ao alvedrio ilimitado, que não existam quaisquer limitações à instituição de um poder arbitrário, absoluto, a cavaleiro de quaisquer princípios de direito natural, de moral, de ética, do bem comum ou da razão, sob pena de o poder constituinte não ser legítimo.

Nessa vertente, dê uma olhada nestas questões, que demonstram uma visão cambiante, ora focada na vertente jurídica, ora na vertente política, que admite limitações de ordem suprapositiva:

(CESPE/Defensor Público BA/2010) O Brasil adotou a teoria segundo a qual o poder constituinte originário não é totalmente ilimitado, devendo ser respeitadas as normas de direito natural.

Resposta: Errado.

Comentário: aqui, a Banca foi expressa quanto à adoção, pelo Brasil, da tese exposta na ADI 815, rel. min. Moreira Alves.

(FCC/TRE SE/Analista Judiciário/Área Judiciária/2015) Ora, (...) 'se uma norma constitucional infringir uma outra norma da Constituição, positivadora de direito supralegal, tal norma será, em qualquer caso, contrária ao direito natural', o que, em última análise, implica dizer que ela é inválida, não por violar a 'norma da Constituição positivadora de direito supralegal', mas, sim, por não ter o constituinte originário se submetido a esse direito suprapositivo que lhe impõe limites. Essa violação não importa questão de inconstitucionalidade, mas questão de ilegitimidade da Constituição no tocante a esse dispositivo, e para resolve-la não tem o Supremo Tribunal Federal – ainda quando se admita a existência desse direito suprapositivo – competência . O trecho acima transcrito, retirado do voto do Ministro Moreira Alves na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 815 (DJ de 10/05/1996), que não adotou a tese:

c) das normas constitucionais inconstitucionais, de Otto Bachof.

Comentário: a banca adotou a tese do Supremo Tribunal Federal, que não adotou a concepção **jusnaturalista** da Constituição, ou em sentido **axiológico ou valorativo**.

(Instituto AOC/Procurador/Pref. Pinhais/2017)

c) O Brasil, conforme doutrina majoritária, adotou a corrente positivista, segundo a qual nem mesmo o direito natural limitaria a atuação do poder constituinte originário .

Resposta: Correto.

Comentários: Nosso Supremo Tribunal Federal não acolheu a teoria jusnaturalista, considerando que, no Brasil, todas as normas contidas na Constituição Federal (pelo menos até o momento) possuem igual dignidade constitucional. Como decorrência desse entendimento, as normas originárias da Carta Constitucional (que não foram alteradas por Emenda à Constituição) não podem ser declaradas inconstitucionais. Mas podem ser alteradas ou suprimidas por Emenda à Constituição, mas por outro Poder, o Legislativo, desde que não se refiram a limitações materiais explícitas (cláusulas pétreas) ou formais. Seguindo a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, no acórdão III-ZR-153/50 de março de 1951, que rechaçou a possibilidade do controle de constitucionalidade de norma constitucional originária, ao analisar a Lei Fundamental da Bonn, erigida sob os auspícios do governo de ocupação aliado e não sob uma assembleia constituinte alemã legítima, o nosso STF nos autos da ADI 815, rel. Min. Moreira Alves, igualmente assentou a impossibilidade de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias.

(Cespe/TRT 8ª Região/Analista Judiciário/Área Judiciária/2016)

d) Embora seja, em regra, ilimitado, o poder constituinte originário pode sofrer limitações em decorrência de ordem supranacional, sendo inadmissível, por exemplo, uma nova Constituição que desrespeite as normas internacionais de direitos humanos .

Resposta: Correto.

Comentário: Aqui, o Cespe considerou válida, em tese, o entendimento de que existem limites supranacionais ao poder constituinte originário, consagrados em determinados **valores políticos, ideológicos ou institucionais**.

(Instituto AOC/Procurador/Pref. Pinhais/2017)

b) De acordo com a corrente jusnaturalista, o poder constituinte originário estaria limitado ao direito natural. Assim, na elaboração de uma nova constituição, deveria-se respeitar certos imperativos do direito natural .

Resposta: Correto.

Comentários: Questão que se referiu à concepção **jusnaturalista** de Constituição, não adotada pelo STF.

(Cespe/Procurador do Ministério Público junto ao TC-DF/2021) O poder constituinte originário, embora reconhecidamente não absoluto em sua integralidade, não se subordina hierarquicamente a normas jurídicas anteriores na acepção jurídico-formal.

Resposta: Correto.

Comentários: o que significa "Não absoluto em sua integralidade"? No âmbito do direito internacional, não seria admissível uma Constituição que desrespeitasse os direitos da pessoa humana, o respeito à soberania e a independência nacional e além de outros limites de ordem natural (valores éticos superiores). Corrente jusnaturalista na primeira parte da questão.

A dica portanto, é: se a banca se referir expressamente **à posição adotada pelo STF**, não é a vertente jusnaturalista. Ou seja, o Supremo não admite o controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias. Se a banca se referir ao poder constituinte originário **em geral**, é possível haver limitações supranacionais ou de caráter político, social, ético e cultural às normas constitucionais originárias.

Poder Constituinte Derivado(PCD):

É também chamado de **remanescente, secundário, instituído, constituído ou de segundo grau**, é previsto no próprio texto constitucional, e representa **o poder de alterar a Constituição, dentro das regras por ela estabelecidas**.

Por sua vez, o Poder Constituinte Derivado divide-se em:

Poder Constituinte Derivado Reformador: é o poder competente para modificar o texto da Constituição, respeitando-se o regramento estabelecido pela própria Constituição Federal. Na CF/88, ele é exercido pelo Congresso Nacional, na forma do artigo 60 da Constituição (**processo de emenda constitucional**).

Poder Constituinte Derivado Revisor: a revisão constitucional está prevista no art. 3º do ADCT e consistiu em um **procedimento simplificado**, que ocorreu **apenas uma vez: cinco anos** após a promulgação da CF/88. As emendas foram aprovadas por **maioria absoluta** de votos em **sessão unicameral** do Congresso Nacional. Ademais, o texto foi promulgado pela **Mesa do Congresso Nacional**.

ADCT: Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral .

Poder Constituinte Derivado Decorrente: é a competência que têm os **estados-membros**, em virtude de sua autonomia político-administrativa, de **elaborarem suas próprias Constituições**. Mesmo nesse caso, o exercício do poder constituinte derivado está sujeito a diversas limitações, a exemplo dos princípios constitucionais sensíveis, estabelecidos e extensíveis.

O **poder constituinte derivado decorrente inicial ou instituidor** corresponde à capacidade de os Estados instituírem suas constituições, nos termos do art. 125, § 1º, da CF:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

O **poder constituinte derivado decorrente de revisão estadual ou reformador ou de segundo grau** compreende o poder de atualizar a Carta Local, nos termos previstos na própria Constituição.

O entendimento majoritário atualmente é de que o poder constituinte derivado decorrente é exclusivo **dos Estados membros e também do Distrito Federal**, conforme assentado pelo STF, **não se estendendo aos Municípios** (ao elaborarem suas leis orgânicas). Lembre-se de que a Lei Orgânica do DF possui uma parte de competência estadual e uma de competência municipal:

"A Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento normativo primário destinado a regular, de modo subordinante – e com inegável primazia sobre o ordenamento positivo distrital – a vida jurídico-administrativa e político-institucional dessa entidade integrante da federação brasileira. Este ato representa, dentro do sistema de direito positivo, o momento inaugural e fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma palavra: a Lei Orgânica equivale, em força, autoridade e eficácia jurídicas, a um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente **equiparável às Constituições promulgadas pelos Estados-membros**" (RCL 3436/DF-MC, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 1º/7/2005)

O poder constituinte derivado tem como **características**:

i) é um poder **jurídico** e não político, pois integra o direito positivo, está presente no texto constitucional;

ii) é **derivado**, pois haure sua força e autoridade do poder constituinte originário;

iii) é **subordinado**, pois se encontra limitado pelas normas expressas e implícitas na Constituição Federal, as quais não poderá contrariar ou abolir;

iv) é **condicionado**, pois seu exercício deve obedecer às condições estabelecidas no texto da Constituição;

v) **limitado**, pelas limitações materiais expressas ou implícitas, além das limitações formais e circunstanciais (art. 60, CF);

vi) como consequência do que dissemos anteriormente, as normas constitucionais resultantes do poder constituinte derivado (alteradas por emenda constitucional) **podem sofrer controle de constitucionalidade**, podendo ser declaradas eventualmente, inconstitucionais.

Poder Constituinte Material e Formal

O poder constituinte pode ainda ser classificado em poder constituinte **material** e poder constituinte **formal**.

Essa conceituação distingue dois momentos na elaboração de uma Constituição: (i) a ideia, a concepção de uma nova ordem constitucional; e (ii) a formalização do texto escrito da Constituição.

Em outras palavras, primeiro concebe-se uma nova Constituição, trata-se ainda de uma ideia (uma decisão política, que constitui o **poder constituinte material**).

Posteriormente, elabora-se o texto da Constituição propriamente dito (consubstanciando do **poder constituinte formal**).

Assim, define-se o que é constitucional (poder constituinte material); logo a seguir, atribui-se juridicidade constitucional a essa escolha (poder constituinte formal), por intermédio de um texto consolidado único.

Poder Constituinte Difuso

Cuidado com este termo. O poder **constituinte difuso** diz respeito a um poder de que se reveste o Judiciário (e não o Legislativo), por intermédio de interpretação, e que conduz a mudanças informais do sentido, do significado e do alcance do texto constitucional, sem alterar expressamente seus dispositivos. É o caso típico da mutação constitucional. Assim leciona Uadi Lamêgo Bulos:

"É precisamente no poder constituinte difuso que as práticas constitucionais encontram esteio. São, em essência, fruto dessa manifestação invisível, latente, por meio da qual os poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) continuam a obra do legislador constituinte originário, interpretando disposições vagas, ambíguas ou obscuras, bem como colmatando lacunas, preenchendo, assim, os espaços em branco do produto constitucional legislado" **(BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional . São Paulo: Saraiva, 1997, p. 172)**.

O **Poder Constituinte Difuso** se manifesta, portanto, quando a modificação da Constituição é resultante de um processo informal no qual a criação de suas normas ocorre a partir das tradições e atualizações históricas de uma sociedade, a exemplo das Constituições consuetudinárias. Está ligado ao conceito de mutação constitucional, fenômeno que se verifica nas Constituições ao serem modificadas de forma silenciosa, contínua, sem alteração textual. É isso mesmo, trata-se de um processo informal e espontâneo de alteração da interpretação constitucional, em que se muda o conteúdo de determinado dispositivo, sem mudança no teor da norma. É o que acontece quando o Supremo Tribunal Federal muda seu entendimento sobre certo dispositivo constitucional, por decorrência da própria evolução de usos e costumes.

Fala-se em **Poder Constituinte Demarcado ou Concentrado**, quando o surgimento da constituição resulta da deliberação formal de um grupo de agentes, como no caso das constituições escritas (NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional/ Marcelo Novelino. 11ª. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 65).

Outras classificações:

Conforme leciona Marcelo Novelino, denomina-se **Poder Constituinte Histórico** aquele que estabeleceu a primeira constituição de um Estado, como no caso brasileiro, a Constituição Imperial de 1824); **Poder Constituinte Revolucionário** o responsável por elaborar uma Constituição a partir de um ato revolucionário, como as Constituições brasileiras de 1937 (Constituição "polaca"), outorgada com o propósito de tornar efetiva a Revolução de 1930 e a de 1967, outorgada com o fim de consolidar os atos institucionais que caracterizaram o golpe de 1964; e **Poder Constituinte de Transição Constitucional**, como a Constituição de 1988, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1987 /1988 (NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional/ Marcelo Novelino. 11ª. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 65).



Veja como foi cobrado!

(CESPE/CONSULTOR LEGISLATIVO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2014) O poder constituinte originário tem o condão de instaurar uma nova ordem jurídica por meio de uma nova constituição ou mesmo de um ato institucional.

Correta descrição do poder constituinte originário, que pode se manifestar democraticamente ou por um ato de força.

Gabarito: certo.

(IBFC/PROCURADOR MUNICIPAL/C. STO. AGOSTINHO/2019) Acerca do Poder Constituinte e suas características, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(F) Prevalece o entendimento de que os **Territórios Federais podem exercer o Poder Constituinte.**

O Poder Constituinte originário é o poder de elaborar uma nova Constituição, é exercido pelo povo, diretamente, ou por intermédio de representantes eleitos para uma assembleia constituinte. O poder constituinte derivado reformador e o revisor dizem respeito à possibilidade de modificação da Constituição originária, por meio de Emendas. É exercido pela União, por meio do Poder Legislativo Federal.

Os estados detém o poder constituinte derivado decorrente, para elaboração de suas Constituições. Os territórios federais são simples descentralizações administrativas da União, autarquias territoriais, não detendo autonomia federativa, nos termos do art. 18 da CF:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

(V) O Poder Constituinte Originário instaura uma nova ordem jurídica, rompendo com a ordem jurídica precedente, sendo inicial, autônomo e ilimitado juridicamente.

Certo. O poder constituinte originário possui as seguintes características:

i) é um poder político, e não jurídico, porque antecede a formação do ordenamento jurídico, que tem nele seu fundamento de validade; dentro desta nova ordem jurídica estarão também sendo instituídos os demais poderes constituintes (revisor, reformador e decorrente).

ii) é um poder ilimitado, por não estar restringido pelo direito preexistente, não devendo obediência ao direito positivo antecessor, e podendo mesmo ultrapassar cláusulas pétreas e direitos adquiridos sob o regime constitucional prévio;

iii) é um poder autônomo, isto é, compete somente ao seu titular, o povo, representado ou não, deliberar sobre o conteúdo a ser inserido na nova ordem constitucional. Não se subordina a nenhum outro poder para exercer sua autonomia.

iv) é um poder incondicionado, porque não sujeito a nenhuma forma pré definida de manifestação de sua vontade, nem para elaboração de sua obra, a Constituição;

v) é também um poder permanente, o que significa dizer que é preexistente e que não se exaure com a promulgação da Constituição, permanecendo em estado latente e podendo se manifestar a qualquer momento, seja por meio de uma assembleia constituinte, seja por ato revolucionário;

(V) O Poder Constituinte Derivado Reformador tem a capacidade de modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, estabelecido pelo originário.

Correto, e esse procedimento é previsto no art. 60 da nossa Constituição Federal de 1988:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

(CESPE/PROCURADOR/TCE-ES/2009) No tocante ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente positivista, de modo que o referido poder se revela ilimitado, apresentando natureza pré-jurídica.

CERTO. O Brasil adotou a corrente positivista. Para o positivismo, o poder constituinte originário não sofre limitações, uma vez que a ordem jurídica nasce com ele, não antes dele. Ou seja, não há normas jurídicas anteriores a estabelecer limites para sua atuação. Daí o fato de ser classificado como um poder político ou pré-jurídico, ao contrário do Poder Constituinte Derivado, classificado como jurídico.

Mais recentemente, as bancas vêm relativizando essa visão de ausência de limites do PCO, principalmente quando o enunciado não é explícito quanto à posição do STF sobre a ausência absoluta de limites ao Poder Constituinte Originário. Nesse sentido, o Cespe recentemente anulou questão de Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados (2014), que afirmava que "o poder constituinte originário é ilimitado, não devendo reverência ao direito anterior ou aos valores sociais".

Como o item não se referia à posição do STF, a banca achou por bem anular a questão. Ainda assim, qualquer que fosse o contexto, a violação aos valores sociais ou individuais (direitos humanos) pelo Poder Constituinte Originário seria afirmativa passível de questionamento.

Apenas se a banca referir-se, de maneira geral, à posição do Supremo Tribunal Federal, sobre a ausência de limites do PCO, sem adentrar na seara dos direitos humanos ou de normas supra positivas de ordem moral, ética ou política, você poderá marcar com segurança o item como verdadeiro.

(CESPE/AGU/MMA/2015) Diferentemente do poder constituinte derivado, que tem natureza jurídica, o poder constituinte originário constitui-se como um poder, de fato, inicial, que instaura uma nova ordem jurídica, mas que, apesar de ser ilimitado juridicamente, encontra limites nos valores que informam a sociedade.

Gabarito: certo.

O Cespe vem se aproximando da corrente doutrinária que afirma o Poder Constituinte Originário como ilimitado do ponto de vista jurídico, mas que deve obedecer a uma **"estrutura de padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade"**, além de **princípios de direito internacional e princípios de justiça**, conforme assinala **(J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da Constituição apud Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, 2014.)**

(FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE SP/2012) Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), um dos inspiradores da Revolução Francesa, foi autor de um texto que teve grande repercussão na teoria do Poder Constituinte. O referido texto é:

- a) Que é o terceiro Estado?
- b) O poder do terceiro Estado.
- c) Que pretende o terceiro Estado?
- d) Que tem sido o terceiro Estado?
- e) A importância do terceiro Estado.

O poder constituinte originário (PCO) é o poder inovador por excelência, e foi defendido de forma pioneira pelo Abade Sieyès, em sua obra "O que é o terceiro Estado?" publicada em 1789. Segundo Sieyès, o Poder Constituinte Originário decorre da soberania titularizada pelo povo para organizar o Estado e instituir uma nova ordem constitucional e jurídica.

O Abade elaborou esta obra com fundamento na doutrina do "Contrato Social", de Jean Jaques Rousseau, e vislumbrou a existência de um poder imanente à Nação (poder constituinte) e superior aos dois outros poderes ordinariamente constituídos: a nobreza e o clero. Permitiu, assim, legitimar a ascensão do povo ao poder político, configurando desse modo o "Terceiro Estado".

Gabarito: alternativa "a".

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960